

1500203-92.2021.8.26.0472
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Receptação
Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA
Comarca: Porto Ferreira
Foro: Foro de Porto Ferreira
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 24/02/2022
... (grifos nossos):

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA PARA INTERIOR DA RESIDÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar pessoal executadas por autoridade policial sem a existência da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Porto Ferreira
Foro de Porto Ferreira
2ª Vara
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, . - Centro
CEP: 13660-017 - Porto Ferreira - SP
Telefone: (19) 3581-2201 - E-mail: portoferr2@tjsp.jus.br

1500203-92.2021.8.26.0472 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500203-92.2021.8.26.0472
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DANIEL BENTO REZENDE

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de DANIEL BENTO REZENDE, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 180 do Código Penal afirmando que em data não especificada, mas entre os dias 28 de fevereiro e 02 de março de 2021, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, recebeu e transportou um monitor de vídeo da marca Philco, uma lanterna de LED para bicicleta marca White Led, dois alto falantes (tweeters) marca Unlike, um par de luvas de ciclista marca Expert Riders, um relógio de pulso marca Games, um fone de ouvido marca Lyco., um óculos de sol sem marca, um HD externo 500gb marca LG, um capacete de ciclista sem marca e nove peças de roupa, objetos avaliados globalmente em R\$ 4.000,00, pertencentes a Paulo César Bortolin de Almeida e que sabia serem produtos de crime.

Segundo narrou denúncia, "os objetos acima descritos foram furtados da residência da vítima Paulo Cesar entre os dias 27 e 28 de fevereiro de 2021, nesta cidade e comarca, período no qual se encontrava em viagem, tendo o crime sido por ela verificado ao retornar, quando acionou a Polícia Militar e comunicou o ocorrido

(cf. boletim de ocorrência às fls. 04/07 e depoimento à fl. 48). Após, o denunciado, em data não especificada, recebeu os objetos furtados e, no dia 02 de março de 2021, durante a noite, os estava transportando pela rua em uma caixa de papelão quando foi surpreendido por policiais militares, no que demonstrou nervosismo e passou a caminhar mais rápido. Os agentes públicos realizaram então a abordagem do denunciado e, averiguando os objetos na caixa, constataram que dentre eles havia uma bolsa com o nome da vítima impresso, no que esta foi acionada e reconheceu os bens como sendo os furtados de sua residência dias antes. É certo que o denunciado tinha ciência de que os objetos que recebeu e transportava eram produto de crime, pois o fazia a noite, de forma dissimulada (no interior de uma caixa de papelão), sem qualquer documentação, tendo demonstrado nervosismo e caminado mais rápido aos avistar os policiais, apresentando a inverossímil versão de que os encontrou em uma construção abandonada, embora de considerável valor global (R\$ 4.000,00), sem se olvidar de seu notório conhecimento sobre o meio criminoso, haja vista a vasta folha de antecedentes que possui, notadamente pela prática de crimes patrimoniais (fls. 57/77)."

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

As provas juntadas pela acusação são ilícitas.

1 Ilegalidade da abordagem motivada por nervosismo

Os policiais justificaram a abordagem em razão do "nervosismo" da pessoa imputada. Tal argumento não tem sido aceito pela jurisprudência. Isso pode ser remontado ao item 4 do Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603616, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, publicado em 10/05/2016) (aplicado por analogia):

(...) a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias (...)

Ou seja, para que a busca domiciliar e pessoal sem mandados judiciais seja válida, é necessário que os motivos alegados sejam "sindicáveis", isto é, passíveis de controle por parte da defesa.

Ora, qual defesa efetivamente cabe contra argumentos tais como o "nervosismo"? Não se trata de colocar sob dúvida a palavra do policial, como a posição mais açodada leva a concluir. Trata-se tão somente de estabelecer um padrão pelo qual seja possível o controle da atividade policial, impedindo que tão nobre e essencial atividade seja confundida com o arbítrio.

Aliás, é como o STJ (tribunal responsável pela uniformização do direito processual penal no país conforme art. 105, inciso III, c.c. art. 22, inciso I, ambos da Constituição) recentemente se manifestou (grifos nossos):

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA PARA INTERIOR DA RESIDÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar pessoal executadas por autoridade policial sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, com base apenas em denúncia anônima (art. 240, § 2º- CPP), bem como a prova derivada da busca pessoal.

2. Tendo a busca pessoal ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais (nervosismo ante a presença da autoridade policial e ingresso no interior do imóvel), sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa

causa para autorizar a medida invasiva (ingresso no domicílio, sem ordem judicial), deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.

3. Habeas corpus concedido para declarar ilegal a apreensão da droga e, consequentemente, trancar a ação penal n. 5014975-62.2021.8.24.0033 (art. 386, II - CPP), determinando a restituição da liberdade dos pacientes, se por outro motivo não estiverem presos.

HC 687342/SC, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021.

O Brasil é signatário da CADH, sendo a Corte IDH responsável pela sua interpretação autêntica, conforme a própria Convenção. Desnecessário aprofundar no mérito do recente Prieto & Tumbeiro vs. Argentina (entre outros pontos, a Corte IDH entendeu que a detenção baseada em alegado "nervosismo" por parte dos policiais está sujeita a uma subjetividade tal que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com a Convenção), sendo a confissão de culpa do estado argentino (o que afasta o argumento fácil de que o controle da atividade policial não pode ser feito em um país como o Brasil), por si só, suficiente (grifos nossos):

26. En su reconocimiento de responsabilidad internacional, suscrito el 4 de marzo de 2020, el Estado aceptó la totalidad de las conclusiones establecidas por la Comisión en su Informe de Fondo, lo cual incluye las concernientes a que las detenciones de los señores Fernández Prieto y Tumbeiro se enmarcaron en un contexto general de detenciones practicadas sin orden judicial ni supuestos de flagrancia en Argentina. En el mismo orden, en su escrito de alegatos finales de 18 de junio de 2020, el Estado reconoció que este "caso constituye un emblema de lo que se conoció en nuestro país, durante la década del 90, como el 'olfato policial', que implicaba actuaciones policiales descontroladas, incentivadas por políticas de seguridad pública basadas en operativos de prevención discrecionales, sin investigación ni inteligencia previa, y por ello, profundamente ineficientes". Asimismo, el Estado puntualizó que "este tipo de prácticas policiales fueron promovidas por políticas de seguridad que se definían bajo el paradigma de la llamada 'guerra contra las drogas' y que, además, resultaban amparadas por un inadecuado o inexistente control judicial"

E como a exigência de justa causa tem sido estendida inclusive para situações de busca veicular, o fato de os objetos não estarem propriamente colados ao corpo da pessoa imputada não repercutem na análise, visto que ela, conforme a denúncia, estava transportando tais objetos.

2 Impossibilidade de complementação da motivação

Tampouco os antecedentes da pessoa imputada podem servir para justificar a abordagem. Primeiro porque não se trata de motivo idôneo (e como os maus antecedentes não "expiram", admitir tal circunstância como justa causa implicaria uma sujeição eterna da pessoa imputada à invasão pelo estado em sua intimidade, o que não é admitido em uma sociedade liberal). Depois porque não foram alegados pelos policiais quando de sua justificação perante a autoridade policial. E não pode a acusação, posteriormente, completar as razões para a abordagem policial.

De início é preciso esclarecer que não pode um órgão (no caso, o Ministério Público) complementar a motivação do ato administrativo de outro (no caso, os agentes de segurança) quando não se trata de ato complexo ou composto. O que se perfaz com os procedimentos perante a autoridade policial (delegado de polícia) e a autoridade judiciária é tão somente a prisão (mormente pela redação do inciso LXI do artigo 5º da Constituição); de outro lado, o decreto de prisão cautelar é dado exclusivamente pelo juiz singular (ou pelos tribunais na análise de recursos ou em processos de competência originária), de forma que, também por não se tratar de ato complexo ou composto, as deficiências de motivação não podem ser superadas pela

apreciação das instâncias superiores, conforme remansosa jurisprudência do STJ e STF.

Sobre as circunstâncias posteriormente levantadas em audiência e trazidas como fundamentação pela acusação, é de uma clareza meridiana a lição dada pelo Exmo. Ministro Relator no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral do STF (RE 603.616/R0, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015), assunto absolutamente correlato com o agora debatido:

A proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois.

(...)

Ou seja, a validade da busca é testada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois.

Consta do item 5 do acórdão:

Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

Ou seja, se nem mesmo a constatação da flagrância posterior é capaz de justificar a diligência invasiva, muito menos as circunstâncias verificadas a posteriori (em audiência, p. ex.) podem ter tal efeito pretendido.

A questão que se coloca não é se um observador onisciente seria capaz de, naquele momento, encontrar "fundada suspeita" para agir (até porque, no limite, esse raciocínio leva à legalização de toda abordagem que resulte positiva –o que implica nenhum controle judicial sobre a atividade policial, visto que as diligências infrutíferas, que representam mais de 99% dos casos segundo a própria SSP, não são submetidas sequer ao crivo da autoridade policial civil – segundo consta do sítio oficial da corporação (<http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Trimestrais.aspx>), em 2020 foram quase 12 milhões de abordagens (11.961.706) para pouco mais de 100 mil (104.081) flagrantes, ou seja, menos de 1%).

O que se discute é justamente a necessidade de algum controle sobre a atividade de segurança pública e a avaliação dos critérios declinados pelos agentes públicos para justificar as diligências invasivas.

Se existiam motivos corretos (revelados posteriormente) e eles agiram pelos motivos errados, é indubitável a ilegalidade do ato.

A Polícia Militar tem o dever de realizar o patrulhamento ostensivo para cumprir o seu dever de dar segurança à população.

No entanto, em relação às suas diligências que invadam direitos fundamentais é necessário não só a existência de critérios, como também a objetivação destes para que um controle minimamente efetivo possa ser exercido pela sociedade civil, como sucede com qualquer órgão público (art. 5º da Lei de Introdução).

Isso não só está conforme a lei e a constituição, como vimos, como também evita que determinados preconceitos disseminados na sociedade sejam institucionalizados por meio de políticas de estado. Como se sucede com as populações em situação de rua, ou de determinada classe social ou determinada etnia.

Ainda em relação à interpretação teleológica, é preciso retomar os números da Secretaria de Segurança Pública, a qual, anualmente, realiza um número de abordagens correspondentes a mais de 1/4 da população local.

Seria indicativo de uma política de segurança efetiva caso os índices de sucesso não fossem miseravelmente baixos (inferiores a 1%), o que denota a falta de critérios com as quais tais abordagens são feitas.

Ou seja, o estado impõe um custo muito alto na liberdade dos cidadãos para um ganho demasiado pequeno na segurança. Isso se torna especialmente grave quando se tem em vista que estas abordagens não são bem distribuídas socialmente, recaindo sobremaneira naqueles grupos que a sociedade enxerga como mais prováveis de estarem associados ao crime, seja pela região onde moram, seja pela etnia, seja pela idade,

seja pelo sexo etc.

Neste contexto, a decretação da nulidade da diligência cumpre a finalidade (é adequada) de desincentivar comportamentos dos órgãos públicos que atinjam de modo indevido os direitos fundamentais da população.

E a decretação da nulidade torna-se necessária porque as mais de 11 milhões de abordagem infrutíferas não são submetidas a um controle externo, sendo a declaração de invalidade das diligências positivas o único momento de traçar limites às atividades de segurança por parte do estado.

Portanto, ainda que se negue a função eficaz de bloqueio das garantias fundamentais e as submetam a um juízo de proporcionalidade, ainda assim o resultado do processo permanece intacto.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório para ABSOLVER DANIEL BENTO REZENDE das acusações a ele imputadas na denúncia nos termos do inciso II do art. 386 do Código de Processo Penal.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 24 de fevereiro de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA